

1500023-41.2021.8.26.0516
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Apropriação indébita
Magistrado: LUIZ HENRIQUE ANTICO
Comarca: Roseira
Foro: Foro de Roseira
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 03/11/2022
... dos Santos, RJDTACRIM 27/162).

"TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Confissão informal - Negativa na delegacia - Confissão no ANPP - Prisão posterior - ANPP rescindido - Silêncio em juízo - Depoimento de agente policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Roseira
Foro de Roseira
Vara Única
Rua Dom Epaminondas, 54, Roseira-SP - cep 12580-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500023-41.2021.8.26.0516 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500023-41.2021.8.26.0516
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2050912/2021 -
DEL.POL.ROSEIRA, 16371392 - DEL.POL.ROSEIRA, 251/20/206 - DEL.POL.ROSEIRA, 2050912
- DEL.POL.ROSEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOÃO PAULO DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ HENRIQUE ANTICO

V I S T O S

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada que a Justiça Pública intenta contra JOÃO PAULO DE CARVALHO, apontado como transgressor do disposto no artigo 171, "caput", do Código Penal, porque, no dia 24 de outubro de 2020, em horário incerto, na Avenida Portugal, nº 340, Bairro Barretinho, nesta cidade, o acusado teria obtido, para si, vantagem ilícita no valor de R\$ 1.045,00, em prejuízo de ADILSON NUNES MACHADO, induzindo-o em erro, mediante ardil. É da acusação que o réu fora procurado pela vítima para lhe ajudar com o saque de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através de aplicativo do "smartphone" "Caixa Tem". Assim é que, com o intuito de se apoderar da importância, o acusado disse que realizaria o procedimento através de seu próprio celular, transferindo-o, na

sequência, ao ofendido. Passando-se pela vítima, nos dias 24/08/20 e 26/08/20, o acusado efetuou dois saques na conta do ofendido, contudo, ao contrário do que havia prometido, jamais os transferiu ao beneficiário.

O acusado foi beneficiado com o acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal – fls. 78. O benefício foi revogado pela decisão copiada à fls. 93.

Denúncia recepcionada à fls. 101.

Resposta à acusação apresentada à fls. 115, sem preliminares, exceções ou rol de testemunhas. Foi examinada pela decisão de fls. 117 que manteve o recebimento da acusação.

O processo seguiu seu curso normal com a oitiva da vítima, decretando-se a revelia do acusado – fls. 151 e 152.

Em manifestação lançada à fls. 159 o Ministério Público protestou pelo reconhecimento da procedência da ação penal, com a condenação do agente nos termos da denúncia, pois comprovado o meio fraudulento empregado, consistente na simulação de que transferiria o dinheiro à vítima, isto depois de convencê-la a permitir com que, fazendo uso de seu próprio celular, realizasse o saque se passando por ela. Opinou pela fixação da pena no mínimo legal, com aplicação do regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direito.

A defesa manifestou-se à fls. 175 procurando invalidar as confissões do acusado, ao argumento de que o crime a ele imputado não restou configurado, tendo agido em estado de necessidade, pois à época passava por dificuldades. De forma alternativa, em caso de condenação, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão.

Esta a apertada síntese dos autos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A prova quanto à materialidade do delito tem respaldo nos relatos apresentados pelo ofendido. Como se trata de dinheiro, não foi possível a sua apreensão, mas isto não afeta a materialidade da infração, pois nos termos do permitido pelo artigo 167 do Código de Processo Penal há sua supressão pela prova testemunhal, caracterizando-se o corpo de delito por testemunhas.

“Não sendo possível o exame de corpo de delito direto por terem desaparecido os vestígios, dispensa-se a perícia, fazendo-se a prova do crime inclusive pelo depoimento de testemunhas. Deve haver, porém, uma prova testemunhal cabal sobre a materialidade do delito” (Código de Processo Penal Interpretado – pg. 229 – Júlio Fabbrini Mirabete).

“O art. 158 do CPP exige exame de corpo de delito direto ou indireto quando a infração deixar vestígio; mas o art. 167 lhe contempera o rigor, dizendo que, quando não for possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Precedentes do STF (RTJ 81/110).

“O exame de corpo de delito é suprável por prova testemunhal (art. 167 CPP), não havendo nulidade se a falta do laudo não impede a prova do fato pelo outro meio de prova” (RT 564/400).

Demonstrado ficou que o acusado de fato praticou o delito que lhe é irrogado pela denúncia ministerial.

O réu, além de revel, é confitente. Tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, durante a audiência em que foi beneficiado com o acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, admitiu a autoria do crime de estelionato, realizando, em nome da vítima, saques em seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), contudo, diversamente do que haviam combinado, jamais entregou os valores a quem de direito - fls. 12 e 77 - audiência gravada pelo sistema Teams.

"... Uma das características da confissão, como prova, é a da relatividade de seu valor. Por isso, o juiz deve confrontar a confissão com os demais elementos probatórios dos autos para ver se é compatível com estes. Já a confissão extrajudicial é insuficiente, por si só, para lastrear a condenação, embora possa ser admitida como prova suficiente quando amparada por outros elementos..." (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INTERPRETADO - pg. 250 - JÚLIO FABBRINI MIRABETE).

"CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - Harmonia com os demais elementos dos autos - Condenação - Possibilidade - Posterior retratação - Irrelevância: A confissão extrajudicial, em harmonia com os demais elementos dos autos, é suficiente para autorizar condenação, inobstante posterior retratação em Juízo" (Apelação nº 819.013/6 Julgado em 22/09/1.993, 9ª Câmara, Relator: - Evaristo dos Santos, RJDTACRIM 19/75).

"PROVA - Confissão extrajudicial Valor: A confissão extrajudicial, em harmonia com os demais elementos dos autos, é suficiente para autorizar condenação, inobstante posterior retratação em Juízo" (Apelação nº 934.747/1, Julgado em 12/04/1.995, 9ª Câmara, Relator: - Evaristo dos Santos, RJDTACRIM 27/162).

"TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Confissão informal - Negativa na delegacia - Confissão no ANPP - Prisão posterior - ANPP rescindido - Silêncio em juízo - Depoimento de agente policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório - Desclassificação inviável - Condenação mantida - Pena e regime adequados ao caso concreto - Recurso improvido (voto n. 46254)" (TJSP - Apelação Criminal 1520985-47.2019.8.26.0228; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2022; Data de Registro: 07/06/2022).

No mais, a precisa narrativa do ofendido deixa claro o embuste praticado pelo acusado, com o objetivo de obter vantagem patrimonial ilícita, isto em detrimento do sujeito passivo. Nesse sentido a narrativa de ADILSON NUNES MACHADO, que disse ter solicitado ajuda do réu para o saque de valores de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), isto por meio do aplicativo denominado "Caixa Tem". Relatou que o réu era seu conhecido e, em razão de dificuldades com a tecnologia, lhe pediu ajuda para o saque. Passado algum tempo, ao perceber que várias pessoas estavam recebendo e o declarante não, resolveu procurar pelo acusado, que disse que o pedido ainda aguardava análise. Posteriormente, foi até a Caixa Econômica Federal e descobriu que o saque havia sido feito pelo acusado, que até hoje não devolveu os valores - fls. 151 - audiência gravada pelo sistema Teams.

Não há dúvida, portanto, da autoria do crime pelo acusado, que enganou a vítima e usando seu próprio celular se fez passar pelo ofendido, conseguindo a liberação dos valores, bem como se utilizando do dinheiro.

O comportamento doloso por parte do acusado ficou evidente. O fato de ter usado seu próprio celular para o saque, assim como ter direcionado o dinheiro para sua conta já é sintoma do dolo prévio, inclusive afastando a possibilidade de desclassificação para o crime de apropriação indébita, no qual o dolo é posterior à

posse ou detenção da coisa alheia.

O engodo por parte do réu consistiu em fazer a vítima acreditar que seira necessário o uso do próprio celular para viabilizar o saque.

Isso reforça, com toda clareza, o elemento subjetivo, ou seja, o dolo do acusado.

Houve efetiva vantagem patrimonial ilícita por parte do increpado, principalmente porque fez uso do dinheiro da vítima e jamais o devolveu. Ora, se realmente estivesse de boa-fé, despido do propósito de enganar a vítima, decerto que teria devolvido os valores, evitando, inclusive, este processo.

Acontece que o momento consumativo do crime definido no artigo 171 do Código Penal, segundo leciona Júlio Fabbrini Mirabete - Código Penal Interpretado - pg. 1.104 - "ocorre quando o agente obtém a vantagem econômica indevida, em prejuízo de outrem, ou seja, quando a coisa passa da esfera de disponibilidade da vítima para o agente".

O crime de estelionato existe quando o agente emprega qualquer meio fraudulento, induzindo alguém em erro ou mantendo-o nessa condição e conseguindo, assim, uma vantagem indevida, com lesão patrimonial alheia, exatamente como no caso vertente.

Pouco importa para a configuração do crime que o prejuízo para a vítima tenha sido efetivo ou não. Ainda assim, a lesão patrimonial efetiva-se.

O estelionato é crime material, cuja consumação se dá no momento e local em que o agente obtém vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

"O estelionato é crime material de dano, tendo o seu momento consumativo quando obtém o agente indevida vantagem patrimonial após ilaquear a boa-fé da vítima" (HC 131.038).

"A vantagem ilícita aludida no art. 171 do CP não consiste, necessariamente, na transmissão da propriedade. Qualquer proveito, mesmo a liberação das obrigações, a prestação de serviços ou o simples uso de coisa cuja posse foi fraudulentamente adquirida, basta para integrar o estelionato" (JUTACRIM 41/133).

"O que se pune no estelionato é a censurabilidade do ato, face à parte subjetiva do delito, vale dizer, o dolo do agente, que, ciente e consciente, visou à prática criminosa, contribuindo para o resultado doloso e enganoso da vítima" (RT 527/381).

A tese da defesa, quanto ao estado de necessidade, está totalmente descartada.

O artigo 24, "caput", do Código Penal dispõe que se considera em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Ora, em que pese a alegação da sempre combativa defesa, não há nos autos a mínima prova que seja de que o acusado teria cometido o crime para salvar perigo atual. Para caracterizar a excludente que legitima a ação do agente, é necessária a ocorrência de um perigo atual, e não um perigo abstrato e eventual. Atualidade do perigo é a probabilidade de dano imediato ao bem jurídico e, assim, abrange o que está prestes a acontecer, ou seja, o perigo iminente; pois a pessoa não é obrigada a esperar que o perigo se torne atual.

O ônus da prova, segundo regra do artigo 156 do Código de Processo Penal, cabe a quem o alega, no caso específico ao imputado.

"Ônus da prova (ônus probandi) é a faculdade que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive da paridade de tratamento das partes" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado - pg. 220).

"Quem invoca um álibi, para ser absolvido, carece de cumpridamente demonstrá-lo, não bastando, para tal fim, produção de elementos de convicção que não excluam de vez a possibilidade de ter sido o autor da infração" (Ap. 53.726 - TACRIMSP).

"Iterativa a jurisprudência no sentido de que, quem apresenta um álibi, deve comprová-lo satisfatoriamente, sob pena de ser tido como réu confesso" (Rev. 37.688 - TACRIMSP).

"Recurso em Sentido Estrito - Rejeição de denúncia por falta de justa causa - Furto de gêneros alimentícios - Excludente de ilicitude - Estado de necessidade - Inocorrência - Entendimento Na medida em que a peça inicial acusatória descreve fatos típicos, previstos no art. 155, § 4º, I, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, com todas as suas circunstâncias, atendendo ainda aos demais requisitos formais previstos no art. 41 do CPP, é de rigor o seu recebimento. O fato de alguém estar atravessando por dificuldade financeiras é justificativa inaceitável para a prática de ilícitos, uma vez que a excludente de ilicitude do estado de necessidade só pode ser reconhecida na hipótese de implicar no sacrifício de um bem de valor menor ou ao menos igual do que o bem protegido" (TJSP - Recurso em Sentido Estrito 0078023-48.2016.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 27/03/2018).

Com efeito, tendo por configurada a infração penal irrogada ao acusado, impõe-se a dosimetria da pena a ser aplicada, observado o sistema trifásico previsto pelo artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal favorecem ao acusado - fls. 58 e 60. Foi até mesmo beneficiado com o acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal - fls. 78. Com efeito, sua pena-base é fixada no mínimo legal, isto é, em um (01) ano de reclusão.

A despeito da confissão ser atenuante genérica prevista pelo artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, a pena deve ficar inalterada, eis que já foi fixada no mínimo legal e as atenuantes não podem trazer a pena aquém do patamar mínimo.

"PENA - Redução - Inadmissibilidade - Fixação no mínimo legal - Circunstâncias atenuantes que não tem o condão de reduzi-la abaixo do mínimo - Recurso não provido. As atenuantes não permitem a redução da pena abaixo do mínimo previsto na lei para o crime" (Apelação Criminal n.º 151.790-3 - Barueri - Relator: Breno Guimarães - 2ª Câmara Criminal - V.U. - 07.08.95.).

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas, além de causas especiais de aumento e diminuição de pena, tornando-se a fixada em definitiva.

A pena pecuniária deve atender aos mesmos critérios da pena privativa de liberdade.

Deve ser traçada dentro dos parâmetros previstos nos artigos 49, § 1º, e 60, "caput", ambos do Código Penal, no que toca ao número de dias-multa e seu valor, no mínimo em decorrência dos antecedentes e situação econômica do indigitado que não parece ser promissora.

O regime inicial do cumprimento de pena do acusado é o ABERTO, conforme estabelece o artigo 33, § 2º, alínea "c", do declinado diploma, com as condições do artigo 115 da Lei de Execução Penal.

É possível contemplar o acusado com uma das penas alternativas introduzidas pela Lei nº 9.714/98. A pena aplicada não supera a 04 anos de prisão, preenchendo o agente as demais condições subjetivas consagradas pelo artigo 44 e respectivos incisos do Código Penal.

Como a condenação (pena imposta) foi igual a um ano, é possível operar-se a substituição por uma pena restritiva de direitos (prestação pecuniária), na forma do artigo 43, inciso I, c.c. artigo 44, § 2º, c.c. artigo 45, § 1º, todos do Código Penal. Fiz expressa opção pela prestação pecuniária por entender que apenas a multa seria insuficiente para prevenção e repressão. Além disso, o delito já prevê multa cumulativa em seu preceito secundário. No mais, é a melhor forma de indenizar a vítima.

"Tem-se definido a pena como uma sanção aflitiva imposta pelo Estado, por meio da ação penal, ao autor de uma infração, como retribuição de seu ato ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico; seu fim é evitar novos delitos. Tem ela esta função preventiva geral, com fim intimidativo a todos os destinatários da norma penal, e especial, dirigida ao autor do delito para o impedir de cometer novos crimes e reintegrá-lo socialmente" (Código Penal Interpretado - pg. 250 - Júlio Fabbrini Mirabete).

Quanto ao valor, deve corresponder a um salário mínimo nacional vigente quando do efetivo pagamento, de conformidade com o que preceitua o artigo 45, § 1º, do Código Penal.

No caso de descumprimento das condições impostas, na conversão deverá ser observado o que dita o artigo 44, § 4º, do Código Penal.

Sendo o réu contemplado com a substituição acima, não há falar-se em concessão da Suspensão Condicional da Pena ("SURDIS") - artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Considerando que o artigo 44 do Código Penal preconiza que as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, persiste a multa imposta cumulativamente.

Em razão da substituição realizada, do regime carcerário imposto, bem como da ausência dos fundamentos que autorizam a prisão preventiva, permite-se ao réu eventual apelo em liberdade.

"RECURSO EM LIBERDADE - Agente solto no curso do processo - Ausência de motivos para a prisão preventiva - Possibilidade - Ocorrência - Inteligência: art. 393, I do Código de Processo Penal, art. 324, III do Código de Processo Penal, art. 323 do Código de Processo Penal, art. 185 do Código de Processo Penal. Tendo o agente permanecido solto no curso do processo, sem que a sentença tivesse aludido a motivos que autorizassem a sua prisão preventiva, deve ser admitido o recurso em liberdade (voto vencido)" (Habeas Corpus nº 216.436/0, Julgado em 27/12/1.991, 5ª Câmara, Relator designado: - Ribeiro dos Santos, Declaração de voto vencido: - Paulo Franco, RJDTACRIM 13/172).

"Se durante a instrução do feito o réu se manteve em liberdade, não se esquivou do processo nem procurou de alguma forma embaraçar o seu desenvolvimento ritual, desaconselhável se torna a segregação durante a tramitação de recurso baseada simplesmente em Maus Antecedentes reconhecidos na sentença, pois após o advento da Constituição Federal vigente no país, não se concebe a figura do culpado provisório

e, portanto, da custódia simplesmente decorrente de sentença condenatória não definitiva" (Habeas-Corpus nº 287.950/5, Julgado em 05/03/1.996, 13ª Câmara, Relator: - Abreu Oliveira, RJTACRIM 29/312).

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a Ação Penal, CONDENANDO o acusado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um (01) ano de reclusão (REGIME ABERTO), e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo nacional vigente à época do efetivo pagamento, a ser pago à vítima, de conformidade com os artigos 43, inciso I, c.c. 45, § 1º, ambos do Código Penal, mantida a pena de multa, por infração ao artigo 171, "caput", do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no livro destinado ao rol dos culpados, oficiando-se para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, bem como remeta-se cópia da presente decisão para a vítima, para conhecimento, como determinado no artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

LUIZ HENRIQUE ANTICO
Juiz de Direito

Roseira, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA